

1500530-28.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500530-28.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083994/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 23890649 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 1833/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2083994 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS OLIVE DEPIANTTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

VINICIUS OLIVE DEPIANTTI está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, cumulado com o artigo 302, "caput", do CTB, observado o concurso material entre as infrações.

Notificado (fls. 206), o réu apresentou defesa (fls. 213).

A denúncia foi recebida em 13 de junho de 2022 (fls. 215/216) e o réu foi citado (fls. 283).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 288).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 302/308).

A defesa teceu considerações acerca da dosimetria da pena e requereu a aplicação das benesses legais (fls. 319/335).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 4/6 e 7/8), boletim de ocorrência (fls. 9/12 e 103/106), fotografias (fls. 26/37 e 50/70), auto de exibição e apreensão (fls. 74/76), laudo necroscópico (fls. 157/159), informação (fls. 162/164), laudo pericial (fls. 274/276), além da prova oral.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu relatou ter sido contratado por Jaqueline (passageira do veículo, a quem já havia prestado serviços de transporte anteriormente) para ir até São Paulo apanhar uma "mercadoria" e, apenas durante o trajeto, tomou conhecimento de que se tratava de drogas ilícitas. No dia do ocorrido, Jaqueline saiu sozinha, voltou com o carro já carregado com os entorpecentes e iniciaram o retorno para a cidade de Aracruz/ES. Quando foram abordados e o policial determinou que estacionasse o veículo, ela o mandou acelerar, ao que obedeceu e empreendeu fuga. Pouco antes do viaduto, Jaqueline lhe pediu que fizesse uma curva bruscamente, ocasião em que perdeu o controle do veículo, que rodou na pista. Nunca havia transportado drogas anteriormente. Negou estar em alta velocidade no momento do acidente, até por conta do peso da carga, ou que tivesse percebido alteração na suspensão veicular por essa razão. Havia acordado receber R\$4.000,00 pelo transporte, mas apenas após a entrega. Negou ter conhecimento de que Jaqueline (que faleceu no acidente) estivesse envolvida com o tráfico.

O policial militar Rafael relatou ter procedido à abordagem do veículo conduzido pelo réu logo após a cancela do pedágio, pois ele aparentava estar carregando muito peso e estar realizando uma viagem longa. Durante a diligência, o réu apresentou respostas confusas e aparentava estar nervoso, então determinou que estacionasse o veículo para fiscalização, ao que ele arrancou e saiu em alta velocidade. Iniciou uma perseguição, todavia, após cerca de 5 quilômetros, perdeu o veículo do réu de vista e informou o ocorrido, via rádio, aos policiais que estavam na região. Logo em seguida, foi informado, via COPOM, que um veículo idêntico havia sofrido um acidente e, quando chegou ao local, constatou se tratar do mesmo carro. Os ocupantes estavam gravemente feridos, especialmente a passageira. Acionou os bombeiros e recolheu os tijolos de maconha que haviam sido lançados na rodovia (cerca de 240 kg). O motorista do veículo, malgrado estivesse desorientado, acabou confessando informalmente que transportaria as drogas até o Estado do Espírito Santo e que perceberia o importe de R\$4.000,00 para tanto. Sabe que a passageira do veículo faleceu após o acidente. Por sua experiência, acredita que o excesso de velocidade tenha motivado o acidente, pois o viaduto do qual o veículo despencou fica em uma curva.

O policial militar Luís Augusto confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega de farda.

A testemunha Neilson narrou que conhece o réu há 10 anos, sabe que ele trabalhava e nunca ouviu comentários acerca do envolvimento dele com entorpecentes.

A testemunha Larissa disse que conhece o acusado desde o começo do ano e sabe que ele trabalhava como motorista de aplicativo.

Pois bem. O réu admitiu, sob o crivo do contraditório, haver sido contratado para transportar os entorpecentes, pelo que perceberia o importe de R\$4.000,00.

A justificativa do réu para a prática do delito não o beneficia. Além de ser pouco crível que ele não soubesse de antemão a natureza da substância, ele disse que tomou conhecimento de sua ilicitude durante o trajeto. Ainda assim, optou por continuar a viagem, malgrado pudesse ter buscado outros meios de voltar para casa. Digno de nota que não há prova (ou sequer alegação) de coação irresistível.

Em adição, o fato de o réu não comercializar diretamente o entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

Também restou demonstrada a causa de aumento prevista no inciso V do artigo 40, Lei de Drogas, já que o acusado admitiu que transportava a droga entre o Estado de São Paulo e o do Espírito Santo, onde residia antes de ser preso.

Noutro giro, os policiais militares narraram que o réu acelerou o veículo e saiu em alta velocidade com o claro escopo de evitar sua prisão em flagrante, já que sabia da existência das drogas.

A alta velocidade, própria de uma situação de fuga, foi tão grande que o réu conseguiu despistar a viatura que o seguia e somente foi abordado após cair de um viaduto.

O próprio acusado admitiu haver tentado realizar uma curva brusca à direita, momento em que perdeu o controle do veículo. E o laudo necroscópico de fls. 157/159 atestou que a morte da vítima Jaqueline se deu por "traumatismo cranioencefálico em decorrência dos ferimentos recebidos" (fls. 159).

No mais, o policial mencionou que foi o peso do automóvel um dos motivos que chamou a sua atenção para realizar a abordagem, o que, somado ao fato do réu ser motorista profissional, corroboram a sua imprudência na condução do veículo e a violação do artigo 28 do CTB, condutas determinantes para o óbito da vítima.

Nesta toada, de rigor a total procedência da ação, pois os delitos imputados ao acusado restaram suficientemente demonstrados.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base do tráfico deve ser majorada, considerando a expressiva quantidade de maconha apreendida - mais de 243kg (fls. 74/76). Assim, fixo-a acima do mínimo legal em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. No que tange ao delito

previsto no art. 302, CTB, fixo no mínimo legal de 2 anos de detenção.

Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Assim, mantenho as penas nos patamares acima indicados.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06. Destarte, aumento a pena do tráfico de 1/6 para 8 anos e 9 meses de reclusão e 875 dias-multa.

Por fim, a despeito das alegações ministeriais, reputo aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de segura comprovação de que o réu se dedicasse a essa atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa, notadamente em virtude de sua primariedade.

Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3. A esse respeito, oportuna a citação do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, esposada em seu voto no Habeas Corpus nº 111.097-MG:

"Destarte, se se entender pela ocorrência de bis in idem em decorrência da consideração das circunstâncias atinentes à quantidade e à qualidade da droga na majoração da pena-base e na dosagem da minorante do § 4º da Lei de Drogas, o magistrado ficará sempre adstrito à aplicação da minorante na fração máxima, tornando letra morta o preceito legal que determina seja ela aplicada na forma escalonada, por isso, a conclusão há de ser pela ausência de sobreposição, notadamente porque a pena-base e a minorante têm finalidades distintas: a primeira encontra justificativa na sanção necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e a segunda visa a contemplar, com o abrandamento da punição, não necessariamente com a fração máxima de 2/3, o agente primário e de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INSTRUMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. MENOR FRAÇÃO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do e Supremo Tribunal Federal especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP, dada a quantidade e a espécie de entorpecente encontrado em poder do acusado. 3. Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.403.921-MG – 2011/0085663-6 – 6ª T – rel. Ministro Vasco Della

Giustina, 23.08.2011, v.u.).

Portanto, considerando a quantidade de entorpecente apreendida, reduzo a pena de 1/6 para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa.

Considerando o concurso material, as penas deverão ser somadas, nos termos do art. 69, CP.

Apesar da primariedade do réu, considerando a soma das penas, os motivos esposados na primeira fase e a gravidade concreta dos delitos, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Aplicável ao réu, ainda, a pena de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 1 ano, considerando-se a natureza do delito, as circunstâncias dos fatos e os termos do art. 293 do CTB.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a

teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu VINICIUS OLIVE DEPIANTTI, qualificado nos autos, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 729 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º c.c. artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, e à pena de 2 anos de detenção e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano, pela prática do crime previsto no artigo 302, CTB, em concurso material. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas, que deverão ser somadas, na forma do art. 69, CP.

O acusado respondeu ao processo preso e agora, com maior razão, não poderá apelar em liberdade, tendo em vista que continuam presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente em virtude da necessidade de impedir a reiteração criminosa. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Nos termos do art. 63 da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos bens e do dinheiro apreendidos com o acusado.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P.I.C.

Jaú, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA